

A black and white illustration of a hand holding a scale of justice. The hand, wearing a striped sleeve, is positioned in the center, holding the beam of the scale. The scale has two pans, each containing a group of small, stylized figures representing people. The figures on the left pan are slightly higher than those on the right, suggesting a balance or a slight tilt. The background is plain white.

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS.

CARTA NOTARIA MARIA LOURDES CUEVA LIV
FECHA DE INGRESO: 10 FEB 2017

Arbitraje seguido entre:

(Demandante)

Y

(Demandado)

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

Tribunal Arbitral

Abog. Ángel Antonio Espinoza Trelles

Arbitro Único

Secretario Arbitral

Abog. Hedi Ivonne Torres Santos

JR. 28 DE JULIO Nº 893. 2DO PISO, OFICINA 03.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227 - CEL. 962500690- 962571255
EMAIL : ABOG HEIDITORRES@HOTMAIL.COM

EXP N° 016-2016

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

RESOLUCIÓN N° 11.

En Huánuco a los 09 días del mes de febrero del año 2016, el Árbitro Único designado por la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "TORRES Y TAPIA" de la ciudad de Huánuco, pronuncia el siguiente Laudo:

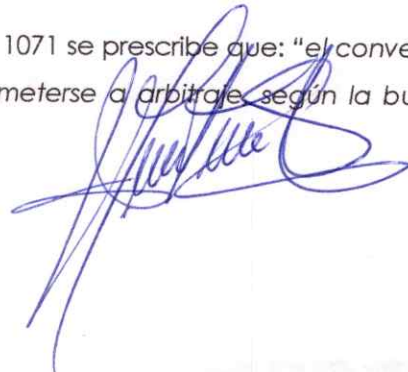
VISTO: El Expediente N° **016-2016**, seguido por las empresas EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. e INVERSIONES MILKA E.I.R.L.; SOBRE SESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Y OTROS.

I. CONVENIO ARBITRAL.

El convenio arbitral se encuentra incorporado en el Contrato de Consorcio Asociativo de fecha 26 de enero del 2015 suscrito entre EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. e INVERSIONES MILKA E.I.R.L. teniendo como base el haber obtenido la Buena Pro en la licitación pública N° 004-2014-UNDAC referida a la obra: **"CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO - REGION PASCO"**, convocada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION de PASCO, la misma que ostenta CLAUSULA ARBITRAL contenida en el numeral DECIMO TERCERO del predicho contrato;

Así mismo, en el numeral 1 del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1071 se establece que: "el convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza". El numeral 5 del mismo cuerpo legal precisa que: "se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte, sin ser negado por la otra".

A fortiori en el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 1071 se prescribe que: "el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje según la buena fe, se



determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos";

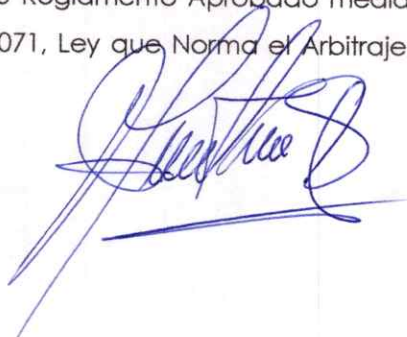
En el caso de autos y considerada la facultad de decidir sobre la existencia de una controversia entre las partes, se autorizó a un tercero, que en este caso es el Centro de Arbitraje Nacional E Internacional "TORRES Y TAPIA" (en adelante el Centro de Arbitraje), a que adopte tal decisión; siendo así, el representante legal de la EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. (en adelante el demandante) ERIK LUIS LOPEZ SCHUTZE identificado con DNI N° 04341162, con domicilio legal en AV. SAN MARTIN S/N OXAPAMPA - PASCO, peticiona el inicio del proceso arbitral;

Al respecto, mediante resolución N° 01 el Centro de Arbitraje Torres Tapia corre traslado a la emplazada para su pronunciamiento sobre la solicitud de arbitraje, de los actuados se tiene la absolución a la solicitud de arbitraje, de donde se desprende argumentos de la demandada atinentes a cuestiones de fondo de la controversia, no existiendo oposición al arbitraje en cuanto procedimiento válido para resolver sus controversias ante el Centro de Arbitraje;

Que, conforme se puede colegir de las actuaciones materiales de las partes y en atención al principio de autonomía de voluntad de las mismas, de *motu proprio* han convenido y consentido en que el convenio arbitral se entienda como una donde someten sus controversias a un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje Torres y Tapia, sustrayéndose voluntariamente de otros ámbitos competenciales.

II. DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL

Al haberse suscitado la controversia entre las partes, el Centro de Arbitraje Torres y Tapia, a través de su honorable corte arbitral designó como Arbitro Único, al Abogado Ángel Antonio Espinoza Trelles. Habiéndose llevado a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal Unipersonal, en las instalaciones del Centro de Arbitraje Torres y Tapia, en dicho acto y entre otros aspectos, se determinó que el arbitraje es Nacional y de Derecho, Así mismo se dispuso que el Proceso Arbitral se regirá por las reglas establecidas en el Acta de Instalación, en lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Arbitraje Torres Y Tapia de Huánuco, el Código Civil, la Ley General De Sociedades, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Legislativo N° 1017, su Reglamento Aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y el Decreto Legislativo 1071, Ley que Norma el Arbitraje en nuestro país, todo sin perjuicio de las



materia susceptible de ser arbitrable, ratificando que, al margen de las posturas y posiciones doctrinarias sobre la naturaleza del "de la buena fe" al que También se le denomina principio de probidad. La palabra buena fe proviene del latín bona fides, el cual es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Ella exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso (Más abajo menciona el demandante) La buena fe en los contratos se traduce en la honestidad y lealtad que debe imperar entre las partes. La buena fe exige en los contratos que se cumpla con lo convenido (Más abajo menciona el demandante) Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural, con lo que se permite la aplicación directa y no por vía subsidiaria de la buena fe contractual, que constituye la más importante manifestación del principio general de la mutua confianza en la vida jurídica..... (Más abajo menciona el demandante) En Cuanto Al Cumplimiento De La Obligación: Que, con fecha noviembre del 2014, se convocó el proceso de selección N° 004-2014-UNDAC, con la finalidad de contratar a una persona natural o jurídica quien se encargue de la ejecución de la obra: "INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO - REGION PASCO"; siendo el monto del valor referencial del contrato de ejecución de obra la suma de: S/. 8. 299,174.31 Ocho Millones Doscientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Cuatro Con 31/100 Nuevos Soles. Que, con fecha 21 de enero del 2015 el organismo encargado de las contrataciones de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco, otorgo la buena pro al consorcio denominado "CONSORCIO EMPRESARIAL E&M" conformado por la EMPRESA CONSRTUCTORA ERWI SAC, en adelante el demandante y la empresa INVERSIONES MILKA EIRL, en adelante la demandada, al obtener 87 puntos en la acotada licitación por encima de los demás participantes en el proceso; Que, con fecha 26 de enero del 2015, ambas partes suscribieron y formalizaron la constitución del contrato de consorcio asociativo para la ejecución de la obra : "INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO - REGION PASCO" generándose un vínculo de carácter contractual obligándonos a cumplirlo en su totalidad y en todos sus aspectos; y que en la actualidad la obra se encuentra culminada al 100 % y en proceso de recepción, empero se tiene que existe la valorización Nro. 13 correspondiente a la obra en mención que asciende al monto de lo que solicito se

LA UNIVERSIDAD Y SE OREDENE A LA MISMA SU INMEDIATO PAGO A FAVOR DEL RECURRENTE.

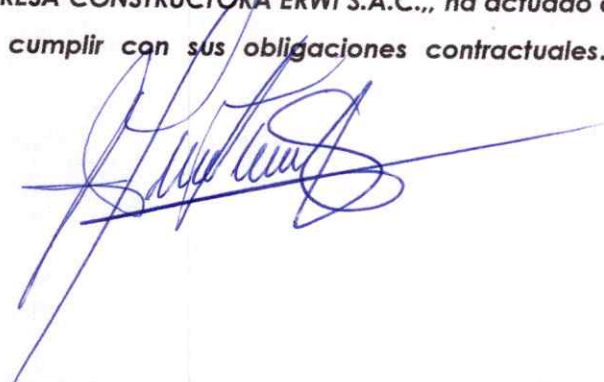
- b. PRETENSIÓN PRINCIPAL NÚMERO DOS: SOLICITO QUE EL ÁRBITRO QUE EN DECISIÓN FUNDAMENTADA DELIMITE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN SOBRE CONTRATO DE CONSORCIO PERFECTO Y DE ESA MANERA IDENTIFIQUE AL CONSORCIADO QUE CONTRAVINO EL PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL AGRAVIANDO LOS INTERESES COMERCIALES DEL RECURRENTE. CONSECUENTEMENTE:
- c. PRETENSIÓN ACCESORIA DERIVADA DE PRETENSIÓN PRINCIPAL NÚMERO DOS: SOLICITO QUE EL ÁRBITRO SANCIONE A LA EMPRESA INVERSIONES MILKA EIRL Y LA OBLIGUE A PAGAR UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DE MI REPRESENTADA ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 300.000.00 TRESCIENTOS MIL NUEVOS SOLES. POR EL DAÑO CAUSADO.
- d. PRETENSION PRINCIPAL NUMERO TRES: SOLICITO QUE EN DECISIÓN DEBIDAMENTE MOTIVADA EL ÁRBITRO AUTORICE LA RENOVACIÓN DE CARTA FIANZA PARA LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL PABELLÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN".

Argumentos Facticos Y Jurídicos De Demanda:

El Consorcio precisa los fundamentos de hecho y derecho de su demanda en los siguientes términos (breve descripción): En Cuanto A La Procedencia Del Arbitraje:

Prima facie, pretendemos justificar el uso procesal del Arbitraje como mecanismo de equilibrio contractual, planteado en este caso contra el consorciado la empresa INVERSIONES MILKA EIRL, en función a las controversias generadas con motivo del Contrato De Ejecución de Obra N° 010-2015-UNDAC; (Más abajo menciona el demandante) Ahora bien, la segunda justificante vendría a ser si el deber de actuar con buena fe es un acto arbitrable tal y como se encuentra definida en el Art. 1362. Del Código Civil peruano, es arbitrable dentro del contexto de las Contrataciones Del Estado (hecho que posiblemente sea procesada puesto que la consideramos como pretensión accesoria); al respecto manifestamos que hemos evaluado las materias que son susceptibles de arbitrar, empero, no hemos ubicado de manera propia a esta encumbrada institución jurídica - filosófica dentro del espíritu de la ley de contrataciones y su reglamento empero si en el Código Civil (Más abajo menciona el demandante) Sustentamos, la procedencia del procesamiento de la falta al principio de buena fe como

ordene a realizar el pago a la universidad y su inmediata cancelación por ser pago a cuenta a favor del recurrente de ordenarse la cesión de posición contractual (Más abajo menciona el demandante) **En Cuanto A La Cesión De Posición Contractual (PRIMERA PRETENSION)** Para tratar este punto debemos delimitar dos temas importantes que han generado la presente controversia, por un lado tenemos al contrato principal generado entre la UNDAC y nuestro consorcio y el contrato que une a los consorciados y las implicancias que este tendría en el primero luego de generado el hecho que la carta fianza de fiel cumplimiento tendría datos inexactos o posiblemente adulterados, cuya entera responsabilidad vendría a ser del consorciado demandado, debido a que al haber trasgredido el principio de buena fe contractual me enviste la potestad de peticionar la modificación de la estructura del contrato de consorcio a efectos de salvaguardar la integridad de la obligación contraída con la UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION consecuentemente planteamos la modificación en forma de SESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL para asegurar y salvaguardar mis derechos económicos frente a la entidad, para tal efecto señor árbitro, deberá a través de fallo justificado despojar la administración del consorciado INVERSIONES MILKA EIRL, para imponerlas a mi representada y de esa manera se pueda sancionar a la empresa infractora, retornándose el equilibrio comercial hasta que la obra haya sido liquidada conforme a ley (Más abajo menciona el demandante) **En Cuanto A La Identificación Del Consorciado Infractor: (SEGUNDA PRETENSIÓN)** Que como quedo establecido en el literal anterior el demandado actuó por encima de los acuerdos detallados en el contrato de consorcio y autorizándose facultades que no están contempladas en el acotado contrato han introducido documentación inexacta que afecta ineludiblemente al recurrente en su condición de integrante del CONSORCIO EMPRESARIAL E & M, por lo que solicito que su despacho identifique las facultades que tuvo el consorciado infractor e inicie las sanciones correspondientes.....(Más abajo menciona el demandante) **En Cuanto A La Indemnización Por Daños Y Perjuicios Y Costos Procesales: (TERCERA PRETENSIÓN)** En cuanto a la obligación del demandado INVERSIONES MILKA EIRL, de indemnizar a la recurrente por los daños y perjuicios económicos que ha ocasionado con motivo de su actuar culposos, manifestamos que solo estamos considerando el DAÑO EMERGENTE más no el lucro cesante puesto que este se encuentra considerada en nuestra pretensión principal, la misma que tiene el siguiente detalle: S/.300, 000.00 incluidos los impuestos de ley, monto que se justifica el asesoramiento debido a la especialidad del servicio brindado..... (Más abajo menciona el demandante) Como se ha desglosado en la presente demanda, mi representada EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C., ha actuado con mucho más que diligencia ordinaria para cumplir con sus obligaciones contractuales.....(Más abajo



normas que pudieran ser aplicables al caso; consecuentemente se declaró aperturado el proceso arbitral, concediéndole el plazo de diez días hábiles a efectos de que la demandante exponga los términos de sus pretensiones, por lo que de acuerdo a los hechos expuestos, el Tribunal Arbitral Unipersonal que expedirá el presente laudo se encuentra conformado por el Abogado Ángel Antonio Espinoza Trelles, conforme es de verse del acta correspondiente.

III. NORMATIVIDAD APLICABLE

De conformidad con lo señalado en el numeral 4) del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, el presente arbitraje se rige de acuerdo a las reglas establecidas en dicha acta, a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1071 Ley De Arbitraje, Decreto Legislativo N° 295 Código Civil Peruano, Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante "la Ley", su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante "el Reglamento", y por la ley N° 26687 Ley General De Sociedades.

Asimismo, se precisó en el acta de instalación que en caso de discrepancias de interpretación, de insuficiencia de reglas o de vacío normativo respecto al contenido del acta, el Arbitro Único resolverá en forma definitiva del modo que considere apropiado, y conforme al artículo 34° y 40° de la Ley de Arbitraje.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA

Pretensiones De Demanda:

El demandante tal y como fluye de autos, plantea su demanda dentro del plazo legal previsto para tal actuación, formulando literalmente las siguientes pretensiones de demanda:

- a. PRETENSIÓN PRINCIPAL NÚMERO UNO: SOLICITO QUE EN DECISIÓN DEBIDAMENTE MOTIVADA EL ÁRBITRO DETERMINE LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DEFINITIVA A FAVOR DE MI REPRESENTADA EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. Y POR LO TANTO SE ME ENVISTA DE TODAS LAS POTESTADES DE ADMINISTRACIÓN Y DECISION SOBRE EL CONSORCIO DENOMINADO "CONSORCIO EMPRESARIAL E&M" EL MISMO QUE TENDRA DIRECTA REPERCUCION SOBRE EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 010-2015-UNDAC REFERIDO A LA "CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO - REGION PASCO" ASI COMO LA POTESTAD DE REALIZAR EL COBRO DE LA VALORIZACION N° 13 POR EL MONTO DE S/. 878,024.26 ANTE

menciona el demandante) **el consorciado MILKA EIRL quien debe ser sancionado y liberado de la administración del consorcio que pretendemos defender.**

V. DESCRIPCIÓN DE LA CONTESTACION DE DEMANDA

Pretensiones De Contestación De Demanda:

El demandado tal y como fluye de autos, plantea su contestación de demanda dentro del plazo legal previsto para tal actuación, conforme se advierte literalmente en los siguientes términos:

Pretensiones De Contestación De Demanda:

Manifiesta el demandado: **que, habiendo sido emplazados con Carta notarial de fecha 03 de diciembre del 2016 remitida por la empresa demandante CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. en la cual nos hace referencia a la potestad de llevar a Proceso Arbitral un pedido expreso de cesión de posición contractual referido a nuestro contrato de consorcio firmado con fecha 26 de enero del 2015, entre mi representada y la hoy demandante mediante la cual formalizaron la constitución del contrato de consorcio asociativo para la ejecución de la obra : "INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO - REGION PASCO" generándose de esta manera un vínculo de carácter contractual que afecta inevitablemente a la UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN ya que los efectos o decisiones que han de tomarse en el presente proceso arbitral tendrán un efecto en nuestra relación contractual principal, siendo así, con fecha diciembre de 2016 fuimos emplazados con demanda arbitral en la misma que consigna entre sus pretensiones textualmente lo siguiente: habiéndonos sometidos a la competencia arbitral de este ilustre centro de Arbitraje, contestamos la demanda y planteamos las siguientes pretensiones de contestación de demanda.... (Más abajo menciona la demandada) **PRETENSIONES DE CONTESTACIÓN: PRETENSIÓN DE CONTESTACION DE DEMANDA ÚNICA: Que, en uso de nuestros derechos comerciales constituidos en la Ley General De Sociedades N° 26887, NOS ALLANAMOS a la presente demanda en su integridad y en los términos consignados por el demandante EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. de los puntos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, y del mismo modo contradecimos la PRETENSIÓN ACCESORIA DERIVADA DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL NUMERO DOS, pretensión que la contestamos en los siguientes términos.... (Más abajo menciona la demandada) **CONTESTACION DE DEMANDA; Que, como******

ha mencionado la demandante en su escrito de postulación con fecha noviembre del 2014, se convocó el proceso de selección N° 004-2014-UNDAC esto a efectos de licitar la obra: "INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO - REGION PASCO"; cuyo valor referencial fue la suma de: S/. 8. 299,174.31 Ocho Millones Doscientos Noventa Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Cuatro Con 31/100 Nuevos Soles. Siendo así con fecha 21 de enero del 2015 la UNDAC nos otorgó la buena pro a nuestras representadas consorcio denominado "CONSORCIO EMPRESARIAL E&M" conformado por la EMPRESA CONSRTUCTORA ERWI SAC, y la empresa INVERSIONES MILKA EIRL, al obtener 87 puntos en la acotada licitación por encima de los demás participantes en el proceso, consecuentemente con fecha 26 de enero del 2015, mi representada y la demandante suscribieron y formalizaron la constitución del contrato de consorcio asociativo para la ejecución de la obra : "INSTALACION DEL PABELLON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DE CERRO DE PASCO - REGION PASCO".....

(Más abajo menciona la demandada) en ese trámite señor y luego de ejecutada la obra en su integridad quedo asentado en el cuaderno de obra en el asiento N° 402 correspondiente al residente de obra, asiento dedicado a la culminación física de obra quedando lista esta para recepción tal y como ordena el Art. 210 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado; consecuentemente mi representada en su condición de administradora de la obra mencionada ha presentado la valorización N° 13 por el monto de S/. 878,024.26 Nuevos Soles La misma que la hasta la actualidad no se ha hecho efectivo pese a ser un pago a cuenta, lo que demostraría que el consorcio ha ejecutado la obra en su integridad, y a satisfacción de la entidad.... (Más abajo menciona la demandada) en ese sentido y habiendo tomado conocimiento que nuestro asesor comercial financiero adscrito a nuestra oficina habría introducido datos inexactos en nuestra CARTA FIANZA induciéndonos a error en perjuicio del CONSORCIO EMPRESARIAL E&M y el de la UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION ya tanto que las fecha de emisión y las fechas de vencimiento no coincidían válidamente empero la carta fianza emitida por el banco continental fue legal y valida al momento de la suscripción del contrato, en tal sentido si bien es cierto que la responsabilidad en integralmente asumida por mi representada ya que el personal a cargo no ostenta vinculo formal con la entidad, somos nosotros como titulares quienes encaramos la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse generado; sin embargo, la obra se encuentra ejecutada al 100% prueba de ello es el acta de recepción ya firmada por los representantes de la entidad, lo que acreditaría que la obligación principal entre UNDAC y CONSORCIO EMPRESAARIAL E&M habría sido

cumplida en su integridad y a satisfacción de la entidad; lo que debe tenerse en consideración; consecuentemente mi representada se encuentra llana de ofrecer y aceptar la cesión de posición contractual en el antedicho consorcio y de esta manera honrar nuestro compromiso con las partes integrantes de este proceso arbitral; por lo tanto nos allanamos a la demanda en los términos predichos y solo contradecimos en cuanto a la obligación de indemnizar ya que el perjuicio económico no existiría, al haberse ejecutado la prestación en su entera integridad;

VI. ITINERARIO DEL PROCESO ARBITRAL:

§ AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

Habiéndose llevado a cabo la audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos el Tribunal Arbitral Unipersonal invitó a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio respecto a la pretensión no allanada. Sin embargo los representantes de las partes señalaron que por ahora no era posible arribar a un acuerdo total o parcial de las posiciones, por lo que el Tribunal Arbitral Unipersonal decidió proseguir con el presente proceso, no obstante, se dejó abierta la posibilidad de que las mismas logren entablar un acuerdo conciliatorio en cualquier etapa del arbitraje.

El Tribunal Arbitral Unipersonal fijó los siguientes puntos controvertidos, en función a las pretensiones planteadas en el presente arbitraje:

De la demanda presentada por el Consorcio:

- a. DETERMINAR SI CORRESPONDE LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DEFINITIVA A FAVOR DEL DEMANDANTE EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. Y POR LO TANTO SE LE TRANSFIERAN TODAS LAS POTESTADES DE ADMINISTRACIÓN Y DECISION SOBRE EL CONSORCIO DENOMINADO "CONSORCIO EMPRESARIAL E&M" ASI COMO LA POTESTAD DE REALIZAR EL COBRO DE LA VALORIZACION N° 13 POR EL MONTO DE S/. 878,024.26 ANTE LA UNIVERSIDAD ASI COMO DE DETERMINAR SI CORRESPONDE OREDENAR A LA UNDAC SU INMEDIATO PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE.
- b. DETERMINAR SI CORRESPONDE LA DELIMITACION DEL ACTO DE ADMINISTRACIÓN QUE PERMITIO AL DEMANDADO OBRAR CONFORME LOS ANTECEDENTES Y DE ESA MANERA IDENTIFICAR AL CONSORCIADO QUE CONTRAVINO EL PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL.
- c. DETERMINAR SI CORRESPONDE SANCIONAR A LA EMPRESA INVERSIONES MILKA EIRL Y ORDENAR EL PAGO UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DEL DEMANDANTE



ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 300.000.00 TRESCIENTOS MIL NUEVOS SOLES. POR EL DAÑO CAUSADO.

- d. DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR LA RENOVACIÓN DE CARTA FIANZA PARA LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL PABELLÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN".

Acto seguido, el Tribunal Arbitral procedió a la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las partes en su escrito de demanda y en su escrito de contestación.

Sin perjuicio de lo expresado, el Tribunal Arbitral se reservó el derecho a disponer oportunamente la actuación de oficio de cualquier otro medio probatorio que considere conveniente, y se reservó la posibilidad de prescindir de las pruebas no actuadas en caso que el Arbitro Único las considere prescindibles o innecesarias.

§ AUDIENCIA DE PRUEBAS

La audiencia pruebas, con la asistencia de los representantes de cada uno de los integrantes del Consorcio, al respecto teniendo en cuenta que los medios probatorios ofrecidos por las partes solo constituyen documentales, se dispuso tenerse en cuenta su mérito al momento de laudar.

§ ALEGATOS Y AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

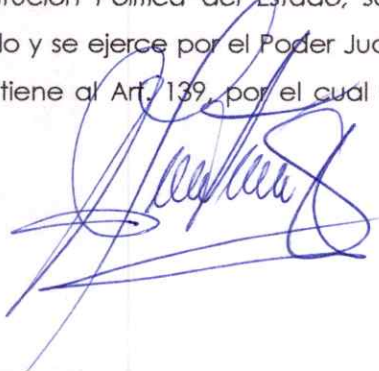
Mediante Acta de Audiencia de Pruebas, el Arbitro Único concedió el plazo de cinco (05) días hábiles para que las partes presenten sus alegaciones y conclusiones finales.

En cuanto a la audiencia de informes orales se tiene que conforme consta del acta respectiva obrante en el expediente, en la que consta la ausencia de pedidos para la realización de esta audiencia especial.

En dicho acto se fijó el plazo para laudar en quince (15) días hábiles, la misma que fue prorrogada por quince (15) días hábiles adicionales:

VII. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARBITRAJE Y ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO:

Conforme al Art. 138 de la Constitución Política del Estado, se tiene que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, en esa misma línea se tiene al Art. 139, por el cual se precisa que: "No existe ni



puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitral". Preceptos que convenientemente han sido desarrollados por el ilustre Tribunal Constitucional, (Exp. N° 6167-2005-PHC/TC-Lima y últimamente Exp. N° 00142-2011-PA/TC). Desprendiéndose que el arbitraje no desplaza al Poder Judicial ni lo sustituye sino que se erige como una institución que complementa el sistema de justicia y que se caracteriza básicamente por ser instrumento destinado a la solución de controversias con un claro contenido patrimonial de libre disposición y de equilibrio comercial, es así que el máximo intérprete de la Constitución reconoce la jurisdicción arbitral, su plena y absoluta competencia para conocer y resolver los actos sometidos a su fuero.

Del mismo modo se aclara que la Carga Probatoria, es principio rector del proceso en general que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, el mismo que tiene desarrollo legal en el artículo 136 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria). Debe destacarse que según HUGO ALSINA¹ el fin de los medios probatorios es producir en el juzgador la convicción sobre los hechos que configuran una determinada pretensión o una determinada defensa. En ese sentido, se tiene claro que la carga de la prueba corresponde a quién alega un determinado hecho, para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto a tales hechos.

Que, de acuerdo al "principio de comunidad o adquisición de la prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al arbitraje, y por consiguiente pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parte que lo ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que "la actividad probatoria no pertenece a quién la realiza, sino por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independiente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que propuso o lo proporcionó."²

Asimismo, debe tenerse en cuenta que "en el arbitraje no prima la verdad probatoria formal, sino que la búsqueda se centra fundamentalmente en torno a la verdad real. Del estudio de los documentos presentados, del desarrollo de la prueba testifical, del resultado de la inspección

¹ ALSINA, Hugo. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial". Buenos Aires: EDIAR, 1942, Tomo II, Pág. 186-188.

² TARAMONA H. José Rubén. "Medios Probatorios en el Proceso Civil". Ed.: Rodhas 1994, Pág. 35.



ocular o de la audiencia directa de las declaraciones de las partes, los árbitros van formando a su convencimiento interior y personal, tanto en el arbitraje interno como en el internacional".³

Es así, que respecto a los sistemas de valoración de la prueba, la doctrina mayoritaria, ha adoptado el sistema de la libre valorización de los medios de prueba –o de la sana crítica–, en virtud de la cual "el juzgador tiene la libertad para valorar los medios de prueba, es decir ya no está sujeto a reglas abstractas preestablecidas por ley, pero su valoración debe ser efectuada de manera razonada, crítica, basada en las reglas de la lógica, la psicología, la técnica, la ciencia, el Derecho y las máximas experiencias aplicables al caso"⁴.

En palabras de FERNÁNDEZ ROZAS, "es una facultad que exige a los árbitros un ejercicio racional y lógico y que en ningún caso puede tener un cariz arbitrario; esto es la referida libertad debe estar sujeta a las llamadas "reglas de la sana crítica", que no han de entenderse como un pretexto para al abuso, sino que presuponen que, una vez analizadas las circunstancias específicas, el árbitro debe realizar de manera prudente un juicio de valor en virtud del cual, la prueba es idónea para los fines del proceso. Incluyen, por tanto, unas referencias lógicas y experimentales que las hacen objetivas y razonables y que las distinguen sustancialmente de la subjetividad absoluta, por lo cual excluyen la posible parcialidad o arbitrariedad del árbitro".⁵

Finalmente, el Tribunal Arbitral Unipersonal deja constancia que en el estudio, análisis y deliberación ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones de las partes, así como todos los medios probatorios aportados y ordenados de oficio, haciendo un análisis y una valoración en conjunto, de manera que la no referencia a un argumento o una prueba no supone que no lo haya tomado en cuenta para su decisión.

Por lo que, considerando lo expresado, el Tribunal Arbitral dentro del plazo fijado para tal efecto, procede a dictar el laudo arbitral, en los siguientes términos:

VIII. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

En tal sentido, el Arbitro Único procede a pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos. Sobre esto último, es menester señalar que el orden fijado en el Acta de Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos es meramente referencial (tal como se hizo

³ FERNÁNDEZ ROZAS. "Tratado del Arbitraje Comercial en América Latina". Volumen II. Ed. Iustel, 2008, Pág.756.

⁴ CASTILLO FREYRE, Mario. "Arbitraje y Debido Proceso". Ed. Palestra, 2007. Pág. 315.

⁵ Ídem. Pág. 757.

reserva de ello), por lo que el Arbitro Único puede variar el orden de los mismos, por una cuestión de lógica.

§ A Modo De Cuestión previa:

Respecto A La Sesión De Posición Contractual En El Ámbito De Las Contrataciones Del Estado:

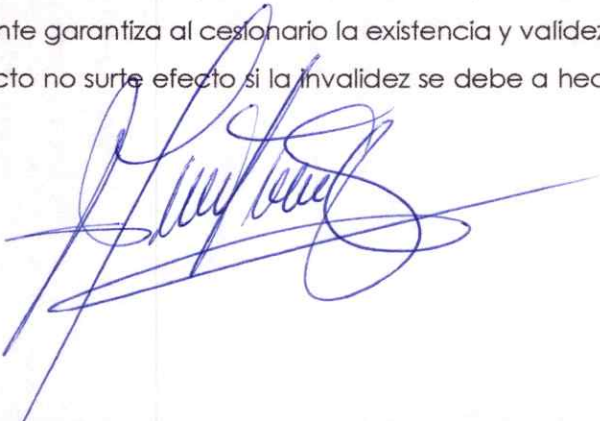
"Los contratos civiles, suponen esencialmente la existencia de los contratantes en pie de igualdad, mientras que en los contratos administrativos las partes se reconocen desiguales, en la medida en que una de ellas representa el interés general, el servicio público, y la otra solamente puede exhibir su propio y particular interés"

No obstante lo señalado, es menester entender que toda relación contractual, incluida una en donde el estado forma parte contratante, debe regir el principio de igualdad inter partes, en la medida de que tanto la entidad estatal como el contratista, deben cumplir las obligaciones que emanan del contrato. Ésta exigencia, así como los vacíos y/o defectos de la normativa en contrataciones estatales, exige que de manera supletoria se apliquen normas de derecho público; por tanto no es raro que de una u otra forma en las ejecuciones de contratos administrativos se utilicen institutos jurídicos propios de los contratos civiles. Al respecto, el Artículo 147° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante Reglamento), establece la posibilidad de que tanto la Cesión de Derechos y de Posición Contractual, sean materia de un proceso de selección en la etapa de ejecución de contrato. Así el citado dispositivo señala que: "en el ámbito de las normas sobre contrataciones del Estado no procede la cesión de posición contractual del contratista, salvo en los casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, cuando se produzcan fusiones o escisiones o que exista norma legal que lo permita expresamente". Lo restringido de dicho mandato, nos obliga en esta oportunidad a esbozar criterios colegiados relacionados a la cesión de posición contractual en el marco de las contrataciones y adquisiciones del estado. La Cesión de posición contractual, es una institución jurídica amparada por nuestro Código Civil desde su artículo 1435° hasta el 1438° y otros dispositivos conexos, en el mencionado corpus iuris. Si bien es cierto la normativa civil no la define expresamente y tan solo se limita a dar sus características y alcances, dicho vacío ha sido aliviado por parte de la doctrina civilista, que en algunos casos la denomina "Cesión de Contrato". Así para algunos "la cesión de contrato consiste en la transmisión de la íntegra posición contractual que una persona ocupa en un determinado contrato" La existencia de ésta figura legal, se refrenda en el hecho de que está "acorde con las necesidades del tráfico jurídico que permite la transmisión subjetiva de la



relación contractual sin modificación de los pactos y condiciones sobrevenidas en el contrato que se transmite" Por ello el artículo 1435° de nuestro Código Civil señala que "en los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual. Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión. Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada previamente al acuerdo entre cedente y cesionario, el contrato sólo tendrá efectos desde que dicho acuerdo haya sido comunicado al cedido por escrito de fecha cierta". Como podemos apreciar, en este acto jurídico, se establece una triangularidad de obligaciones mutuas entre cedente (que es el sujeto contractual que cede su posición en el contrato a un tercero ajeno a los alcances del mismo), el cesionario (representado por el tercero que pasará a ocupar la posición contractual que es cedida por el cedente) y el cedido (que es el otro sujeto contractual primigenio que acepta la cesión formulada por el cedente). Cabe acotar, que es importante diferenciar entre la cesión de posición contractual y el contrato por persona a nombrar regulado en el artículo 1473° del Código Civil, ya que en este último "se acuerda que una de las partes se reserva el derecho de designar a un tercero que finalmente adquirirá la condición de contratante con efecto retroactivo desde el momento de celebración del contrato. En cambio en la cesión de posición contractual no existe tal reserva de nombramiento, ocupando el cesionario la posición contractual del cedente solo a partir del momento en que existe consentimiento para la cesión por parte del cedente, cesionario y cedido" Como podemos apreciar, la cesión de posición contractual viene a ser el negocio jurídico mediante la cual las partes contratantes de un contrato concluido y perfeccionado celebran con un tercero a fin de que este último sustituya a una de ellas en la titularidad de los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual primigenia, la cual se mantiene idéntica en todo su contexto objetivo.

2.2 Reglas aplicables a cesión de posición contractual: El Código civil establece en su artículo 1437° que "el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones y unos y otros son asumidos por el cesionario desde el momento en que se celebre la cesión. Empero, el cedido podrá accionar contra el cedente si hubiera pactado con éste que no queda liberado por la cesión si el cesionario no cumple las obligaciones asumidas. En este caso, el cedido debe comunicar al cedente del incumplimiento del cesionario dentro de los treinta días en que se produjo y, de no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad". Por otro lado, la normativa civil, respecto de este negocio jurídico exige una Garantía de existencia previa y la validez plena del contrato para su consumación; así el artículo 1438° del código civil dispone que "el cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato, salvo pacto en contrario. Este pacto no surte efecto si la invalidez se debe a hecho propio del



795-SELECTED TOPICS IN CHEMISTRY

h contractual, salvo en los casos de tr
arrendados a las Entidades, cuand
legal que lo permita expresamente".

bien cabe que los contratistas puedan ceder, por ejemplo, el derecho al cobro a favor de un tercero, se encuentra prohibido que cedan su posición como obligados frente a la Entidad. De esta manera, el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (entrega de los bienes, prestación del servicio o ejecución de la obra) continuarán a cargo del contratista seleccionado por la Entidad, no pudiendo ser transferidas a ningún tercero. Así, si bien la transferencia de una línea de negocios por parte de un contratista (cedente) a una tercera empresa (cesionario) podría habilitar la cesión de derechos del transferente de dichos activos y pasivos, en el marco de la normativa de contratación pública, este acuerdo habilitaría al tercero cesionario únicamente a recibir el pago de la Entidad cedida por las prestaciones ejecutadas por el contratista cedente. Asumir otras obligaciones pactadas en el contrato (como sería la obligación de entregar los bienes, prestar el servicio o ejecutar la obra) implicaría en realidad una cesión de posición contractual. Así, bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado, la cesión de derechos solamente implica que el tercero cesionario tenga facultades para cobrar el pago por las prestaciones ejecutadas por el contratista cedente. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, como es el caso de la entrega de bienes, prestación del servicio o ejecución de la obra, continuarán a cargo del contratista cedente. Por otro lado, si bien la transferencia de una línea de negocios por parte de un contratista (cedente) a una tercera empresa (cesionario) podría habilitar la cesión de derechos del transferente de dichos activos y pasivos, en el marco de la normativa de contratación pública, este acuerdo habilitaría al tercero cesionario únicamente a recibir el pago de la Entidad cedida por las prestaciones ejecutadas por el contratista cedente. Asumir otras obligaciones pactadas en el contrato (como sería la obligación de entregar los bienes, prestar el servicio o ejecutar la obra) implicaría en realidad una cesión de posición contractual, la misma que se encuentra proscrita por el Reglamento.

En ese orden se tiene la OPINIÓN N° 145-2015/DTN la que en resumen contiene:

"(...) si la figura del fideicomiso se contrapone a lo estipulado en el artículo 147° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Cesión de Derechos y Cesión de Posición Contractual (...). Asimismo, importa saber si cabe la posibilidad de efectuar los pagos correspondientes a la renta mensual a la empresa propuesta por la empresa adjudicada". (sic).

Sobre el particular, corresponde señalar lo siguiente:

2.1 En principio, resulta pertinente distinguir dos figuras que modifican la configuración inicial de un contrato y que tienen consecuencias jurídicas distintas: (i) la cesión de derechos y, (ii) la cesión de posición contractual.



2.2 En relación con la cesión de derechos, debe indicarse que el artículo 1206 del Código Civil, la define como "(...) el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho de exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor." (El resaltado es agregado).

En ese sentido, la cesión de derechos implica que un tercero (cesionario) cuente con todas aquellas facultades que le permitan hacer efectiva la acreencia que tiene el acreedor (cedente) respecto de su deudor (cedido).

Al respecto, el artículo 147 del Reglamento establece que "Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder sus derechos a favor de terceros, caso en el cual la Entidad abonará a éstos la prestación a su cargo dentro de los límites establecidos en la cesión".

Como se puede advertir, la normativa de contrataciones del Estado permite que en los contratos celebrados bajo su ámbito de aplicación se produzca la cesión de derechos, la que se traduce en que un tercero (cesionario) pueda cobrar de la Entidad (deudor cedido) el precio de los bienes, servicios u obras ejecutados por el contratista (cedente).

2.3 Por otro lado, con relación a la cesión de posición contractual, el artículo 1435 del Código Civil establece que "En los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual. Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión (...)."

Así, la cesión de posición contractual supone que la parte cedente –con el consentimiento imprescindible del cedido– transfiere a un tercero cesionario su posición en el contrato, lo que significa que dicho tercero se convierte en el titular de todos los derechos y obligaciones que se derivan del contrato celebrado originalmente entre el cedente y el cedido.

En esa medida, en un contrato celebrado entre un proveedor y una Entidad, el contratista transferiría completamente a un tercero las obligaciones asumidas con la Entidad (entrega de determinados bienes, prestación del servicio o la ejecución de la obra). Asimismo, se haría acreedor de la contraprestación debida por la Entidad, y demás derechos correspondientes al cedente.

Sin embargo, la normativa de contrataciones del Estado prohíbe que aquellas personas naturales o jurídicas que hayan celebrado un contrato con una Entidad, bajo su ámbito de aplicación, puedan ceder su posición contractual a un tercero, pues ello podría vulnerar los principios de Trato Justo e Igualitario y Moralidad.

Así, el artículo 147 del Reglamento, en su segundo párrafo, establece que "En el ámbito de las normas sobre contrataciones del Estado no procede la cesión de posición contractual del contratista, salvo en los casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, cuando se produzcan fusiones o escisiones o que exista norma legal que lo permita expresamente." (El subrayado es agregado).

Esta prohibición tiene sentido en que la obligación de realizar un proceso de selección para determinar a la persona natural o jurídica que proveerá los bienes, servicios y obras requeridos por una determinada Entidad para cumplir con sus funciones, tiene como objetivo fundamental que tal selección se realice en el marco de un proceso competitivo, a efectos que la Entidad pueda satisfacer su necesidad en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio.

No obstante, dicho objetivo podría verse afectado si se permitiera que el postor evaluado y seleccionado en el marco de este proceso, luego pudiera ceder las obligaciones y derechos inherentes a su calidad de parte en el contrato a un tercero ajeno a la relación

contractual, el que, al no haber sido objeto de evaluación durante el respectivo proceso de selección, podría no ser el proveedor idóneo para satisfacer la necesidad de la Entidad contratante.

Debe destacarse que la prohibición de cesión de posición contractual del contratista no es absoluta, sino que, excepcionalmente, la normativa de contrataciones del Estado permite su procedencia en los siguientes supuestos: i) transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las Entidades; ii) cuando se produzcan fusiones o escisiones; o iii) cuando exista norma legal que lo permita expresamente.

Cabe precisar que, cuando el Reglamento comprende entre las excepciones a la regla general antes mencionada a aquellos supuestos en los que "exista norma legal que lo permita", se refiere a una ley que, específicamente, autorice a realizar la cesión de posición contractual en el marco de los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado.

2.4 En virtud a lo expuesto precedentemente, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, solo se permite la cesión de créditos, en virtud de la cual el contratista puede ceder sus créditos frente a la Entidad a un tercero, quien solo tendría derecho a exigir dichos créditos, manteniendo el contratista sus obligaciones frente a la Entidad.

2.5 Ahora bien, conforme al artículo 241 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, "El fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario".

En aplicación de la disposición citada, como resultado de la celebración de un contrato de fideicomiso, el contratista, actuando como fideicomitente en el contrato de fideicomiso, puede ceder sus derechos de crédito frente la Entidad al fiduciario, a fin de que estos integren el patrimonio fideicometido, por lo que el fiduciario tendría la facultad de exigir el cobro de dichos derechos a la Entidad.

Este último supuesto no se encontraría prohibido por la normativa de contrataciones del Estado, toda vez que se estaría realizando una cesión de créditos y no una cesión de posición contractual.

Hecho este breve análisis, pasamos a analizar cada uno de los puntos controvertidos:

§ PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO UNO:

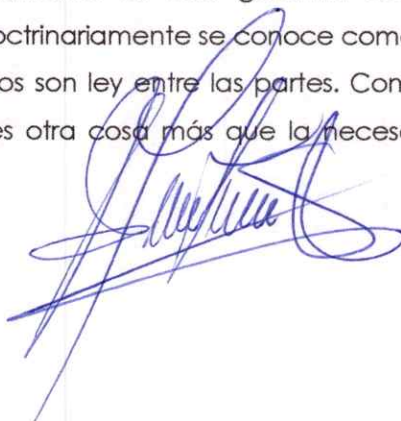
DETERMINAR SI CORRESPONDE LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DEFINITIVA A FAVOR DEL DEMANDANTE EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. Y POR LO TANTO SE LE TRANSFIERAN TODAS LAS POTESTADES DE ADMINISTRACIÓN Y DECISION SOBRE EL CONSORCIO DENOMINADO "CONSORCIO EMPRESARIAL E&M" ASI COMO LA POTESTAD DE REALIZAR EL COBRO DE LA VALORIZACION N° 13 POR EL MONTO DE S/. 878,024.26 ANTE LA UNIVERSIDAD ASI COMO DE DETERMINAR SI CORRESPONDE OREDENAR A LA UNDAC SU INMEDIATO PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE.



Como ha quedado claro en la pre – exposición realizada, la capacidad de facultar a un tercero la posibilidad de transferir o ceder derechos y obligaciones en mérito de un contrato de obra pública – cesión de posición contractual – no se encuentra regulada por nuestro sistema legislativo; por lo tanto, no tiene asidero lógico referirnos en esta parte en lo correspondiente a este punto controvertido, empero, sobre la segunda parte de este pedido arbitral, es decir, sobre el pago de la Valorización Mensual correspondiente al mes de diciembre del prelucido año 2016 Numero 13 por el monto de S/. 878,024.26 (ochocientos setenta y ocho mil veinticuatro con 26/100 nuevos soles)

Prima facie este despacho Arbitral considera necesario tener en cuenta el principio de *Pacta Sunt Servanda*, de aplicación al presente caso. Este principio se encuentra recogido en el Art. 1361 del Código Civil Peruano, esbozado en el siguiente texto "*Obligatoriedad de los contratos.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla*". Como se puede apreciar, la característica principal de dicho principio es que los contratos son obligatorios respecto a aquello acordado libremente por las partes. En tal sentido, este despacho considera que este principio sí resulta aplicable al presente caso, puesto que ha de enfatizar que la voluntad de las partes plasmada en un acuerdo escrito debe ser cumplida obligatoriamente.

El Pacta Sunt Servanda adquiere sentido bajo la lógica que la autonomía de la voluntad de las partes, es la que sustenta a su vez, en gran medida la normativa civil en materia de contratos. En efecto, la regulación en materia civil consiste en permitir que los individuos desarrollen relaciones de cooperación que les permitan intercambiar bienes y servicios en el mercado, logrando así satisfacer sus necesidades. Para tales efectos, el ordenamiento peruano ha dotado a los individuos de la facultad amplia de autorregular tales relaciones de intercambio, en la medida que entiende que son los propios individuos quienes se encuentran en mejor posición para determinar aquello que resulte más conveniente a sus intereses. El Art. 1354 del Código Civil Peruano, recoge dicha autonomía de los particulares, al señalar que "Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo", de lo dicho se deriva una regla básica: Es necesario que el ordenamiento no solo garantice la libertad para generar relaciones contractuales, sino que también las dote de exigibilidad. Justamente es esta garantía de dicha exigibilidad u obligatoriedad de los acuerdos lo que doctrinariamente se conoce como el principio de *Pacta Sunt Servanda*, según el cual los acuerdos son ley entre las partes. Como se puede apreciar, este principio general del derecho no es otra cosa más que la necesaria contrapartida del

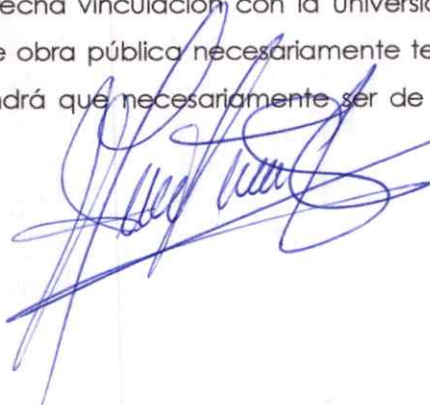


principio de autonomía privada, en la medida que sirve como mecanismo para dotar de eficacia a ésta última, ergo este principio es de aplicación general.

En materia de Contrataciones Del Estado se ha definido al contrato en el numeral 13 del anexo de Definiciones del Decreto Supremo N° 184-2008-EF modificada por D.S. 138-2012-EF (aplicable al caso) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se colige que el Contrato es el "Acuerdo Para Crear, Regular, Modificar O Extinguir Una Relación Jurídica Dentro De Los Alcances De La Ley Y Del Reglamento." Es decir, este es un concepto estrictamente definido para la relación contractual entre el Estado y los particulares, concebida como una relación de dos partes, siendo la única particularidad que una de ellas es el "Estado" sin embargo ello no significa que no se conciba incumplimiento contractual en este marco de contratación, es más, la experiencia ha enseñado que es el ESTADO representado a través de todas las instituciones públicas del país, curiosamente es la que más incumple total o parcialmente los contratos, ello se debe en gran medida a la falta de capacitación de los funcionarios públicos y otras causales que no son motivos del presente laudo, empero se puede concluir que la CAPACIDAD DE INCUMPLIMIENTO está ligada a ambas partes contractuales

Ahora bien, en atención a los fundamentos anteriores, el cumplimiento de un contrato está íntimamente ligado a la obligación que ella reside, puesto que se ha perfeccionado bajo circunstancias mutuas como la buena fe; también queda claro que un incumplimiento contractual generaría inmediatamente la obligación de indemnizar el posible daño que se ha generado con motivo de ese incumplimiento, así lo ha entendido el Art. 1321 del Código Civil y el Art. 170 In Fine del Reglamento De La Ley, "esa es la regla general"; bien, en este estadio este despacho asume la Doctrina Española Respecto A La Indemnización Por El Incumplimiento Contractual, es decir, que a diferencia de una responsabilidad extracontractual la cual necesita obligatoriamente la PROBANZA de quien supuestamente ha sufrido un daño; en la responsabilidad CONTRACTUAL, el deber de indemnizar solo se acreditaría con el simple y llano hecho de su INCUMPLIMIENTO, entonces si existe un incumplimiento debe existir un resarcimiento, salvo que de por medio exista condiciones de inejecución relacionadas al caso fortuito, la fuerza mayor, o la diligencia ordinaria que eximen de responsabilidad al momento de indemnizar;

En el caso que nos ocupa, la relación creada entre los integrantes de este proceso Arbitral a modo de consorcio asociativo y su estrecha vinculación con la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión a raíz de un contrato de obra pública necesariamente tendrá íntima relación puesto que lo que ha de decidirse tendrá que necesariamente ser de conocimiento de la



entidad, y considerando que existen derechos sobre los cuales es menester pronunciarse por ser parte del petitorio arbitral; se tiene entonces la existencia de una obligación esencial contenida en el contrato N° 001-2015-UNDAC donde la entidad se obliga a realizar el pago de las valorizaciones solicitadas por contratista; consecuentemente constituye obligación contractual de la entidad, a la cual debió ser de aplicación el Art. 42 de la ley 27444, que al respecto de la documentación presentada por el administrado menciona: Presunción de veracidad 42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario; bajo este precepto los documentos presentados, tanto por el contratista y el supervisor de obra debieron ser valoradas conforme lo indica el precitado artículo, máxime si de conformidad con el Artículo 197, del Reglamento De la Ley De Contrataciones Del Estado Decreto Supremo 184-2008-EF (Valorizaciones y Metrados) "Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los Metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas"; concluyéndose que debió realizarse el pago de la mencionada valorización, por reunir los requisitos exigidos por ley (contrario sensu el actuar correcto de la entidad hubiese sido observar tal solicitud de pago y la hubiere rechazado, empero eso no ocurrió o en su defecto no se advierte de autos); del mismo modo se debe tener en cuenta La Oportunidad Del Pago De La Valorización de conformidad con el Art. 180 y 181 del Reglamento De La Ley De Contrataciones; siendo que en este caso la demora en el pago de la valorización, generará intereses legales de conformidad con el Art. 48 de la Ley De Contrataciones Decreto Legislativo N° 1017; por lo tanto, este Despacho Arbitral ha evidenciado incumplimiento contractual atribuible a la entidad, puesto que de autos no fluye documental alguna que justifique el incumplimiento deliberado de la entidad, tampoco se advierte de su contestación de demanda argumento válido que inhiba o enerve pronunciamiento respecto de este punto, siendo así, este tribunal conformado por Árbitro Único resolverá en laudo conforme a las consideraciones vertidas en cuanto a este punto.

§ PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO DOS:



DETERMINAR SI CORRESPONDE LA DELIMITACION DEL ACTO DE ADMINISTRACIÓN QUE PERMITIO AL DEMANDADO OBRAR CONFORME LOS ANTECEDENTES Y DE ESA MANERA IDENTIFICAR AL CONSORCIADO QUE CONTRAVINO EL PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL.

Sobre este punto controvertido acogemos lo expresado por la demandada INVERSIONES MILKA E.I.R.L. en su escrito de contestación de demanda presentado por su representante Legal SABY MAYTE LOPEZ TORRES, mediante la cual la mencionada se allana en la demanda, no teniendo objeto pronunciarse sobre la misma.

§ PUNTO CONTROVERTIDO DEVENIDO DE LA PRETENSION ACCESORIA NUMERO DOS:

DETERMINAR SI CORRESPONDE SANCIONAR A LA EMPRESA INVERSIONES MILKA EIRL Y ORDENAR EL PAGO UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DEL DEMANDANTE ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 300.000.00 TRESCIENTOS MIL NUEVOS SOLES. POR EL DAÑO CAUSADO.

Al respecto, se ha dejado claro en el Capítulo V de este pronunciamiento, que la carga de la prueba le corresponde a quien efectivamente afirma los hechos, en este extremo si bien es cierto el demandante alega el daño en su patrimonio producto de la defensa procesal para este caso, no lo ha acreditado materialmente con la aportación de medio probatorio que acredite tal detrimento, ergo solo por ese hecho debe ser desestimada tal petición, empero respecto a los costes de administración del presente proceso arbitral, el criterio de este despacho es el que está contenido en el numeral 29 del Acta De Instalación De Tribunal Arbitral Con Arbitro Único, en ese contexto se ha acreditado de autos que el demandante EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. se ha subrogado en el pago de los costos procesales atribuidos a la demandada INVERSIONES MILKA E.I.R.L. monto que deberá ser reembolsado por la demandada, quien con esta conducta manifestó el interés que tenía en resolver esta controversia, por cuanto adicionalmente se le reconocerá de manera proporcional el pago cubierto por el concepto de gastos realizados por la constatación ocular, lo que se tomará en cuenta al momento de emitir el fallo definitivo.

§ PUNTO CONTROVERTIDO NUMERO TRES:

DETERMINAR SI CORRESPONDE ORDENAR LA RENOVACIÓN DE CARTA FIANZA PARA LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL PABELLÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN"

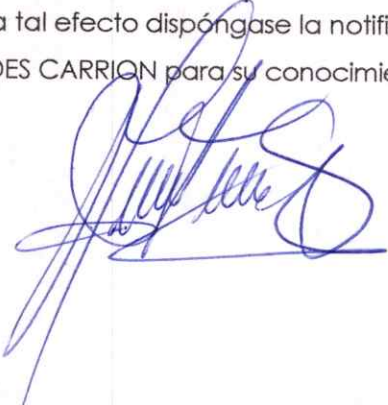
Sobre este punto controvertido se tiene que la obra en ejecución se encuentra culminada al 100% y habiéndose superado el proceso de recepción, este despacho considera que no existe mérito alguno para proceder a ordenar la renovación del mencionado documento, puesto que ya cumplió su finalidad, por lo que se deberá continuar con lo dispuesto en los artículos 210 y 211 del Reglamento De La Ley De Contrataciones y sus modificatorias.

Por ultimo este despacho arbitral deja constancia que para la expedición de este laudo se ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes, examinando las pruebas presentadas por estas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de la libre valoración de la prueba recogido en el Artículo 37 de La Ley De Arbitraje y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido en el acta de instalación y de conformidad con El Reglamento Del Centro De Arbitraje Nacional Torres Y Tapia De La Ciudad De Huánuco y estando a lo dispuesto por la Ley De Arbitraje este tribunal arbitral constituido por arbitro único. En derecho lauda:

SE RESUELVE:

PRIMERO.- fundado en parte el primer punto controvertido: en consecuencia **DECLÁRESE INFUNDADA** la sesión de posición contractual planteada por EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. y **FUNDADA** la demanda respecto al cobro de la valorización N° 13 correspondiente a la obra "Contratación Para La Ejecución De La Obra Instalación Del Pabellón Y Mejoramiento Del Servicio De Formación Académica De La Facultad De Derecho Y Ciencia Políticas De La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión De Cerro De Pasco – Región Pasco", convocada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION de PASCO S/. 878,024.26 (ochocientos setenta y ocho mil veinticuatro con 26/100 nuevos soles) para cuyo efecto **ORDENO** que la demandada INVERSIONES MILKA E.I.R.L. proceda con el cobro de la misma previa autorización notarial de la demandante EMPRESA CONSTRUCTORA ERWI S.A.C. ordenando su co- administración, para tal efecto dispóngase la notificación de la presente a la UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION para su conocimiento.



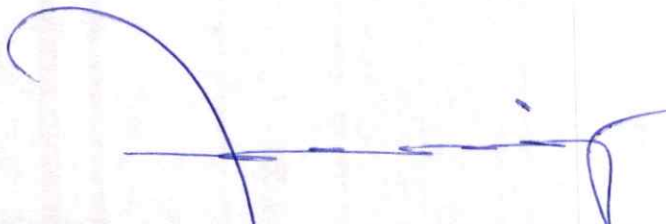
SEGUNDO.- Al segundo punto controvertido: se declara **FUNDADA** la pretensión del demandante por allanamiento de la demandada INVERSIONES MILKA E.I.R.L. en consecuencia delimitada e identificado el consorciado responsable.

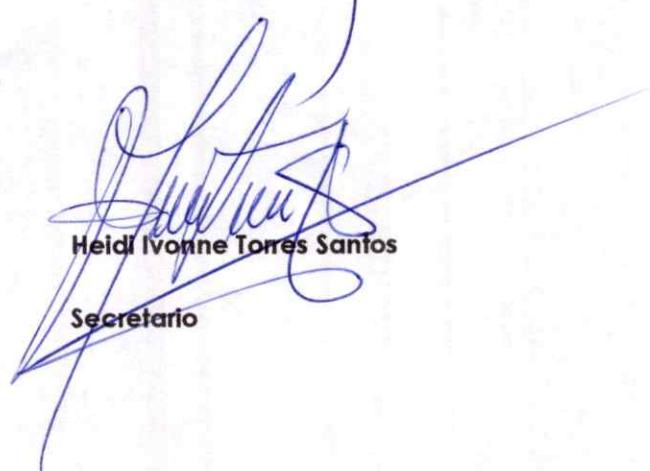
TERCERO.- A la pretensión accesoria derivada del segundo punto controvertido: se declara **INFUNDADA** la pretensión del demandante sobre indemnización por daños y perjuicios.

CUARTO.- Al tercer punto controvertido: se declara **SIN OBJETO** el pronunciamiento sobre pedido de renovación formulado por el demandante.

QUINTO.- En lo que respecta a la imputación de costos arbitrales, ESTESE a lo convenido por ambas partes en cuanto a la asunción de los gastos arbitrales (costos y costas), por lo que corresponde al demandado reembolsar la suma de S/. 10,000.00, por existir subrogación con cargo al demandante.

SEXTO.- Notifíquese con las formalidades de ley.


Firmado: Ángel Antonio Espinoza Trelles -Arbitro Único-


Heidi Ivonne Torres Santos

Secretario